서울고등법원 2019. 9. 26 선고 2017나2034378 판결 [부정경쟁행위금지 등 청구의 소]

재 판 경 과

서울고등법원 2019. 9. 26 선고 2017나2034378 판결

서울중앙지방법원 2017. 6. 15 선고 2016가합534984 판결

전 문

원고, 항소인 1. 주식회사 A

2. B

3. C회사

4. D회사

원고들 소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김범희

피고, 피항소인 주식회사 E

소송대리인 법무변인 연두 담당변호사 손보인

제1심판결 서울중앙지방법원 2017. 6. 15. 선고 2016가합534984 판결

변론종결 2019. 8. 22.

판결선고 2019. 9. 26.

주 문

1. 제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 주식회사 A, B의 각 패소 부분을 취소한다.

피고는 원고 주식회사 A에게 10,000,000원, 원고 B에게 200,000원 및 각 이에 대하여 2016. 6. 28.부터 2019. 9. 26.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고 주식회사 A, B의 나머지 항소 및 원고 C회사, D회사의 항소를 모두 기각한다.

3. 원고 주식회사 A, B와 피고 사이의 소송 총비용의 90%는 원고 주식회사 A, B가, 나머지는 피고가 각 부담하고, 원고 C회사, D회사과 피고 사이의 항소비용은 원고 C 회사, D회사이 각 부담한다.

4. 제1항 중 금전의 지급을 명하는 부분은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

제1심판결을 취소한다. 피고는, 별지 1 목록 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수출, 수입하거나 그 제품의 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 별지2 목록 기재 문구 및 그래프가 사용된 광고물과 별지3 목록 기재 마케팅 자료를 사용하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 있는 별지 1 목록 기재 제품의 완제품 및 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건)과 별지2 목록 기재 광고물 및 별지3 목록 기재 마케팅 자료를 폐기하라. 피고는 원고 주식회사 A에게 150,000,000원, 원고 B에게 30,000,000원, 원고 C회사, 원고 D회사에게 각 10,000,000원 및 위 각 금원에 대하여 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 각 비율로 계산한 금원을 각 지급하라.

이 유

1. 기초사실

제1심판결 이유 중 '1. 기초사실' 부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 인용한다.

2. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)위반 또는 민법상 불법행위 여부에 관한 판단

가. 당사자들의 주장

1) 원고들의 주장

원고 B는 오랜 연구를 통하여 세계 최초로 이 사건 치료방법을 개발하였고, 원고들은 이 사건 치료방법을 실행하기 위한 의료기기의 개발 및 상용화를 위하여 다수의 임상시험과 마케팅을 하는 등 상당한 투자와 노력을 기울였는바, 그 과정에서 약 48억 원의 비용이 지출되었으며, 이러한 자료들은 원고 의료기기의 제조허가 및 사용방법 등에 대한 설명자료에 사용되었다. 따라서 이러한 임상시험자료와 이를 이용한 설명자료 등은 모두 원고들의 상당한 투자와 노력으로 만들어낸 성과물이다.

피고가 제조・판매하는 피고 의료기기는 이 사건 치료방법을 실행하기 위한 것으로 원고 의료기기와 출력주파수, 기본출력파형[1)2)], 전극의 부착위치 및 배치방법이 유사하고[3)], 모양 등의 외형[4)] 및 사용방법도 유사하다. 또한 피고는 피고 의료기기를 판매하면서 원고들의 성과물인 임상시험자료와 이를 이용한 설명자료 등을 무단으로 복제하여 별지2 목록 기재와 같은 문구 및 그래프가 사용된 광고물(이하 '피고 광고물'이라 하고, 이에 대응되는 원고들의 자료를 '원고 광고물'이라 한다)과[5)] 별지3 목록 기재 마케팅 자료(이하 '피고 설명자료'라고 하고, 이에 대응되는 원고들의 자료를 '원고 설명자료'라고 한다. 원고 설명자료는 별지4로 첨부하였다)를 사용하였다.

나아가 피고는 피고 의료기기를 제조하는 과정에서 원고들의 성과를 모방하게 됨에 따라 별도로 임상시험 등의 안정성과 유효성 확인과정을 거치지 않았기 때문에 원고 의료기기 가격인 8,000만 원에 비하여 매우 낮은 2,000만 원에 판매할 수 있게 됨으로써 원고들에게 막대한 피해를 입히고 있다.

위와 같이 이 사건 치료방법을 상용화한 원고 의료기기와 그 안정성과 효능에 대한 공신력을 입증하는 원고의 실적자료들은 성과물인데, 피고는 이와 동일・유사한 피고 의료기기를 제작, 판매하고, 비급여대상 신청이나 영업에 있어서 안정성, 효능에 대한 공신력을 입증하는 원고의 실적자료들을 피고의 의료기기에 관한 것인 양 사용하였다.

피고의 이러한 행위는 원고들의 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 무단으로 도용하여 원고들의 경제적 이익을 침해한 것으로 부정경쟁방지법 제2조 제1호(카)목을 위

반한 것이거나 민법상 불법행위에 해당하고, 이로써 피고는 최소한 351,700,856원을 초과하는 이익을 얻고 있으므로, 피고는 원고들에게 청구취지 기재와 같이 그 행위의 금지 및 침해품의 폐기와 손해배상(일부 청구)을 할 의무가 있다(다만, 이 사건 소송에서 이 사건 특허에 관한 주장은 제외한다).

2) 피고의 주장

원고들은 피고가 자신들의 성과물을 도용하였다고 주장하나, 원고들이 도용하였다고 지적하는 구체적인 자료들은 모두 원고 의료기기에 관한 것으로서 이 사건 치료방법과는 구분되어야 하므로, 원고 B, C, D은 이에 관하여 아무런 투자나 노력을 한 것이 없다.

또한 이 사건 치료방법은 이미 과거부터 있었던 치료방법인 경피신경전기자극에 의한 통증치료 방법의 일종으로 이를 단순히 이론적으로 설명하는 내용에 불과하거나 인간을 대상으로 하는 치료방법에 관한 것으로 특허법상 우리나라에서 독점적인 권리가 인정될 수 없는 것이다. 뿐만 아니라, 원고들이 유사하다고 지적하고 있는 파형은 원고 의료기기의 16가지 파형들 중 하나에 불과하여 전체적으로 피고 의료기기의 8가지 파형과 같다고 볼 수 없고, 전극의 부착위치 및 배치방법도 오래전부터 통증치료 관련 업계에서 일반적으로 사용되던 치료방법에 불과하며, 양 의료기기의 외관도 상당히 다르다. 이와 같이 이 사건 치료방법에 관하여는 독점적인 권리가 인정될 수 없고 피고 의료기기는 그 구체적인 파형과 작동되는 시스템이 구별되는 등 본질적으로 다르다. 또한 원고들이 주장하는 원고 광고물과 설명자료는 원고 의료기기를 단순히 설명한 자료에 불과하고, 그 중 유사한 부분이 있다고 하더라도 이는 관련 연구 논문들을 인용하는 과정에서 유사한 부분이 발생한 것이거나 의료기기의 설명으로서 불가피하게 유사하게 보이는 것이다.

결국 원고 A가 상당한 정도의 투자나 노력을 하였다고 하더라도, 독점적인 권리가 인정되지 않는 이 사건 치료방법에 관한 부분을 제외한 나머지 부분에 관하여 피고가 원고 A의 성과물을 도용하였다고 볼 수 없다.

나. 판단

1) 피고 의료기기와 피고 광고물에 관하여

이 사건 치료방법을 상용화한 원고 의료기기와 원고 광고물이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에 규정된 성과물이라고 하더라도, 앞서 본 증거 및 갑 제25호증, 을 제1, 14호증의 각 기재와 변론

전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하여 보면, 피고가 피고 의료기기와 피고 광고물과 관련하여 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 원고들의 경제적 이익을 침해하였다거나, 민법상 위법한 행위를 하였다고 볼 수 없다.

가) 이 사건 치료방법 사용의 측면

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는데(대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 등 참조), 이는 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 하고, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 고려한 것으로 볼 수 있다. 이러한 점을 고려하면 이 사건 치료방법이나 치료원리를 모방하였다고 해서 이를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반한다거나 민법상 위법한 행위라고 볼 수는 없다.

나) 원고 의료기기 사용의 측면

의료행위 자체가 아닌 의료기기는 특허의 대상이 될 수 있다고 보더라도, 이미 시판되어 공개된 원고 의료기기를 참조하는 행위는 특허나 영업비밀 침해에 해당하지 않는 한 원칙적으로 허용되는 행위로 볼 수 있는데, 원고는 이 사건에서 특허나 영업비밀을 침해당하였다고 주장하고 있지도 않다. 게다가 원고 의료기기와 피고 의료기기는 회로도에서 차이를 보이고 있고, 전극의 부착위치 및 배치방법도 오래전부터 통증치료 관련 업계에서 일반적으로 사용되던 방법이거나 그 응용에 불과해 보인다. 그리고 원고 의료기기와 피고 의료기기는 필연적으로 통증치료 분야에서 일반적으로 사용되고 있는 특성을 공유할 수밖에 없는데, 제출된 증거만으로는 양 기기가 이 정도 수준을 넘어 구체적이고 세부적인 면에서 동일 또는 유사하다고 볼 만한 증거가 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다[피고가 건강보험심사평가원에 이 사건 치료방법에 관한 동등제품으로서 비급여대상 신청을 하면서 원고의 임상시험 자료를 인용하였다고 하더라도, 이는 스크램블 테라피라는 범주의 요법이 임상효과가 있고 피고 제품도 이러한 범주에 속한다는 것에 불과하다고 볼 수 있고, 위 사실만으로 원고 의료기기와 피고 의료기기가 같은 효과를 낸다거나 이 두 제품이 구체적으로 동일 또는 유사하다고 보기에 부족하다. 제1심에서 원고는 갑 제25호증을 들면서 양 기기의 파형이 유사

하다고 주장하고, 피고는 을 제14호증을 들면서 그렇지 않다고 주장하였는데, 원고는 당심에서 양 기기의 파형의 유사성에 대하여 감정신청하여 감정인까지 지정되었으나, 감정인은 감정인 지정 후 1년 6개월이 지나도록 감정비용의 통보조차 하지 않았고, 감정이 지연되어 지정된 기일에서 원고가 감정절차를 계속 진행할 의사를 표시하지 않아 변론이 종결되었다].

다) 원고 광고물 사용의 측면

별지2 피고 광고물과 원고 광고물 사이에 유사성이 인정되는 부분은 관련 학술논문에서 인용된 것으로 단순한 표, 그래프이거나 "약물치료를 받는 만성신경성통증환자 대상 Scrambler Therapy 효과검증" 등 간단하고 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현들이다. 또한 피고 제품이 스크램블 테라피(Scrambler Therapy)라는 범주에 속하고 이 요법이 임상효과가 있다는 것을 보이기 위하여 이미 공개된 원고의 임상시험 자료를 부분적으로 인용하는 행위가 위법하다고 볼 수는 없다.

2) 피고 설명자료에 관하여

피고는 별지3 피고 설명자료에서 별지4 원고 설명자료(갑 제16호증) 1면, 2면 중 '전자극기의 위치설정' 부분, 4 내지 6면을 거의 그대로 사용하였다[별지3 피고 설명자료 4면 '2) 시간설정' 이하 부분부터 8면까지는 원고 설명자료와 유사하지 않으므로 이 부분은 제외한다]. 위 원고 설명자료는 원고 의료기기의 사용방법을 설명하는 일종의 기능적 저작물로서 일반적으로 통용되는 단어나 문구 등을 사용하여 달리 표현하는 것이 불가능한 부분도 포함하고 있지만, 많은 문장(그 문장의 길이가 꽤 긴 것도 포함되어 있다)과 사용법을 설명한 그림 등으로 이루어져 있어 그 창작성이 인정되는 부분도 포함되어 있다. 피고는 이와 다른 표현의 문장 등을 사용하여 같은 내용을 설명하는 것도 얼마든지 가능하다고 보임에도 원고 설명자료를 거의 그대로 사용하였다. 따라서 피고가 피고 설명자료에서 원고 설명자료를 거의 그대로 무단 사용한 것은 원고 A가 상당한 투자와 노력으로 만든 성과물을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 원고 A의 경제적 이익을 침해한 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목을 위반한 행위에 해당한다(원고 설명자료는 원고 A가 제작한 것이므로 원고 A의 성과물이고, 나머지 원고들의 성과물이라고 볼 수는 없으므로, 나머지 원고들의 부정경쟁방지법 위반 또는 민법상 불법행위 주장은 모두 이유 없다).

3. 저작권 침해 여부에 관한 판단

가. 당사자들의 주장

원고 B는 피고가 건강보험심사평가원에 피고 의료기기에 의한 치료행위를 비급여대상으로 신청하면서 원고 B가 저작권을 보유하고 있는 이 사건 각 저작물을 임상시험 자료로 제출하였으므로, 이는 저작권에 대한 침해에 해당한다고 주장한다.

이에 대하여 피고는 이 사건 각 저작물을 사용한 것은 저작권법 제28조의 공정한 인용 또는 제35조의3의 공정이용에 해당하여 원고 B에 대한 저작권침해가 인정되지 않는다는 취지로 주장한다.

나. 판단

원고 B가 이 사건 제1저작물의 저작자 중 한명이고, 피고가 건강보험심사평가원에 피고 의료기기에 의한 치료행위를 비급여대상으로 신청하면서 ① 이 사건 각 저작물의 제목, 임상주요내용, 임상방법, 결과, 결론 등을 기재하였으며, ② 이 사건 제1저작물의 사본을 첨부하여 제출한 사실은 앞서 본 바와 같다.

이 사건 각 저작물의 제목, 임상주요내용, 임상방법, 결과, 결론 등을 발췌하여 기재한 부분은, 피고 제품이 스크램블 테라피(Scrambler Therapy)라는 범주에 속하고 이 요법이 임상효과가 있다는 것을 보이기 위하여 이미 공개된 원고의 임상시험 자료를 부분적으로 인용하는 행위로서 공정한 인용 또는 공정이용에 해당한다고 볼 수 있으므로 저작권 침해행위가 아니라고 봄이 상당하다.

그러나 이 사건 제1저작물의 사본을 첨부한 것은 저작물 전체를 그대로 복사하여 첨부한 것으로 저작권법 제28조의 공정한 '인용'에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 피고의 행위로 피고는 상당한 이익을 얻을 것으로 예상되고, 저작물 전체를 그대로 사본하여 첨부한 점 등에 비추어 이를 공정이용에 해당한다고 볼 수도 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2011도5835 판결 참조). 따라서 피고가 이 사건 제1저작물을 복제한 행위는 원고 B의 공동저작권을 침해하는 행위라고 할 것이다.

4. 금지・폐기청구 및 손해배상 청구에 대한 판단

가. 원고들의 금지・폐기청구에 관하여

앞서 본 바와 같이 피고가 피고 의료기기와 피고 광고물과 관련하여 공정한 상거래 관행이나 경쟁

질서에 반하는 방법으로 원고들의 경제적 이익을 침해하였다거나, 민법상 위법한 행위를 하였다고 볼 수 없으므로, 별지 1 내지 2 목록에 관한 원고들의 금지・폐기청구 부분에 대한 청구는 이유 없다.

한편, 피고는 이 사건 소가 제기된 이후 별지3 피고 설명자료와 다른 설명자료를 사용하고 있음도 앞서 본 바와 같으므로, 별지3 목록에 관한 원고들의 금지・폐기청구 부분도 이유 없다.

나. 손해배상청구에 관하여

1) 원고 A의 청구에 대하여(설명자료 사용에 관한 부정경쟁방지법 위반 관련)

앞서 본 바와 같이 피고가 원고 A의 성과물이라고 볼 수 있는 원고 설명자료를 무단 사용한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목을 위반한 행위에 해당하고 이에 대한 고의, 과실도 있으므로, 피고는 원고 A에게 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

나아가 그 손해액에 대해서 살핀다. 갑 제26 내지 29, 33호증의 기재만으로는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항, 제2항에 의하여 손해액을 산정하기에 부족하므로, 부정경쟁방지법 제14조의2 제6항에 의하여 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 산정한다.

앞서 본 바와 같은 피고의 무단 사용의 정도, 원고 설명자료의 성격, 원고 A와 피고가 직접적인 경쟁관계에 있는 점, 원고 A의 영업에서 원고 설명자료가 차지하는 비중이 그리 높지 않아 보이는 점 등과 같은 제반 사정을 참작하면, 피고의 원고 설명자료 무단 사용으로 인하여 원고 A가 입은 손해액은 10,000,000원 정도로 봄이 상당하다(원고 A가 선택적으로 주장하는 민법상 불법행위로 인한 손해배상액이 위 금액을 넘는다고 볼 수 없으므로, 이에 대하여는 별도로 판단하지 않는다).

2) 원고 B의 청구에 대하여(이 사건 제1저작물 저작권 침해 관련)

앞서 본 바와 같이 피고가 원고 B의 이 사건 제1저작물을 복제한 행위는 그 저작권 침해 행위에 해당하고 이에 대한 고의, 과실도 인정되므로, 피고는 원고 B에게 이로 인한 손해를 배상할 책임이 있다. 피고가 이 사건 제1저작물 전체를 복사하여 국민건강보험법상 비급여대상으로 인정받기 위한 목적으로 사용한 점 등을 참작하여 저작권법 제126조에 의하여 그 손해액을 산정하면, 이 사건 제1저작물의 침해로 인한 손해액은 1,000,000원 정도로 봄이 상당하다. 다만 원고 B는 이 사건 제1저작물의 5인의 공동 저자 중의 한 명이고, 저작권법 제129조에 의하면 공동저작권자는 자신의 지분에 관하여 손해배상청구를 할 수 있는데, 그 지분 비율에 관한 협의 여부나 기여도에 관한 자료가

없어 그 지분은 균등한 것으로 추정되므로(민법 제278조, 제262조 제2항), 원고 B가 입은 손해액은 200,000원(=1,000,000원 × 1/5)이라고 할 수 있다.

3) 소결

따타서 피고는 원고 A에게 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (카)목을 위반한 행위로 인한 손해배상금으로 10,000,000원, 원고 B에게 저작권 침해로 인한 손해배상금으로 200,000원 및 각 이에 대하여 원고가 구하는 이 사건 소장 부본 송달 다음날인 2016. 6. 28.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 당심 판결선고일인 2019. 9. 26.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

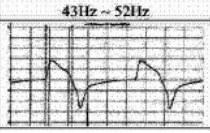
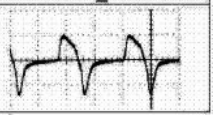
그렇다면, 원고 A와 B의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 원고 A와 B의 각 나머지 청구 및 원고 C와 D의 청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다. 제1심 판결 중 원고 A와 B에 대한 부분은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로, 원고 A와 B의 항소를 일부 받아들여 제1심판결 중 위와 같이 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 A와 B의 각 패소 부분을 취소하고, 피고에 대하여 위 각 금액의 지급을 명하며, 원고 A와 B의 나머지 항소 및 원고 C 및 D의 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 홍승면 판사 구민승 판사 박지연

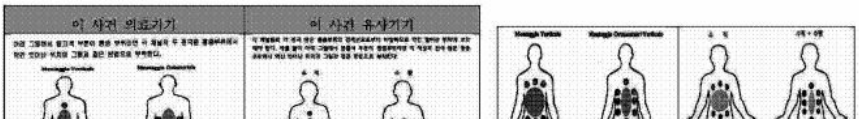
별지

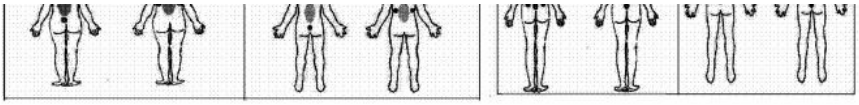
1)이하 각주의 표에 기재된 '이 사건 의료기기'는 원고 의료기기를, '이 사건 유사기기'는 피고 의료기기를 각 의미한다.

2)

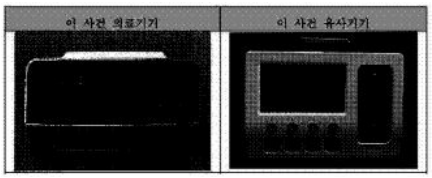
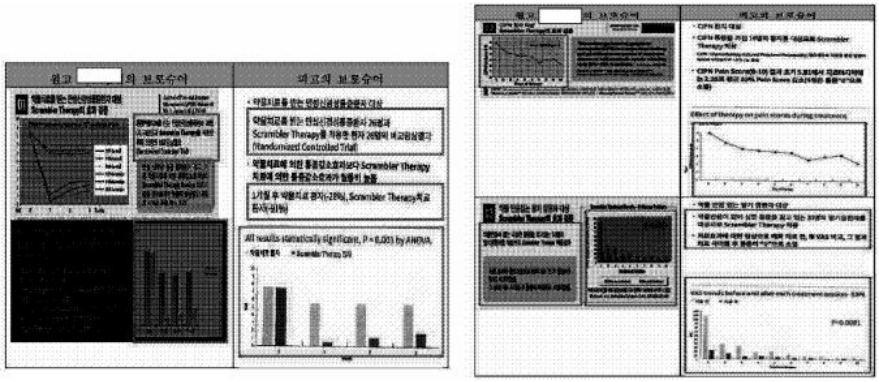
구분	이 사건 의료기기	이 사건 유사기기
최대출력전류	5mA RMS (500Ω)	5.5mA @ 500Ω ± 10% 이내
출력주파수범위	43Hz ~ 52Hz	43Hz ~ 52Hz ± 10% 이내
기본출력파형		

3)





4)



5)